Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810520

Processo nº **0045759-18.2021.8.17.2001**

AUTOR: ADALBERTO LOPES DE ANDRADE

REU: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARATÉR *INAUDITA ALTERA PARS* interposta por ADALBERTO LOPES DE ANDRADE em face da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. igualmente qualificada e representada nos autos.

Aduz, em síntese apartada, que foi diagnosticado com Polineurite Inflamatória (CID 10 G 61.8) pós-COVID e foi prescrito o tratamento com Flebogamma/06, 5 mg por dia, durante 5 dias. Alega que apesar de haver recomendação médica para que continue o tratamento com Imunoglobulina Humana (Flebogamma), a terapia foi negada pelo plano de saúde Réu em maio e junho de 2021.

Requer a antecipação da tutela sem oitiva da parte contrária a fim de que seja compelida a Ré a autorizar o tratamento mensal de infusão de Imungobulina Humana (Flebogamma), de acordo com relatório e determinações dos médicos assistentes. Requer, ao final, seja condenada a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais.

Juntou a negativa de autorização às fls.43/53 (Id. 83252862 e Id. 83252863), o laudo da médica neurologista Dra. Silvana Sobreira Santos, CRM 10.195, às fls.55 (Id. 83252866).

Instada a manifestar-se, a parte Ré apresentou petição às fls.99/106 (Id.83745651) alegando, sem síntese, que que a parte Autora não atende a Diretriz de Utilização de nº 65, conforme os termos da RN no 465/2021 da ANS, artigo 3o, II.

Decisão do juízo *a quo* indeferindo a antecipação da tutela às fls.136/139 (Id. 83862356) e decisão, em sede de agravo de instrumento, da 4ª Câmara cível do TJPE concedendo a tutela antecipada às fls.143/145 (Id. 84468914).

Oportunamente, a Demandada apresentou contestação, às fls.149/158 (Id. 84513952) na qual aduz que a negativa de cobertura do medicamento pleiteado se deu em razão do quadro clínico da parte Autora não preencher os critérios estabelecidos para cobertura, conforme Diretriz de Utilização – DUT n.º 65, Rol 465/2021 da ANS, a qual dispõe precisamente sobre as hipóteses em que o fármaco deve ser autorizado, o que daria amparo legal e contratual à negativa.

Réplica às fls. 199/212 (Id. 87864519).

É o relatório, sucinto.

Passo a decidir.

Ressalto, de início, que o presente feito comporta julgamento antecipado, pois sendo a questão de mérito de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, acho-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto ao seu mérito, nos moldes do art. 355, I, segunda parte do Código de Processo Civil.

Assim que, o cerne da questão posta em pretório cinge-se a saber se **a empresa demandada tem ou não obrigação de custear tratamento para doença que não está em Diretriz de Utilização -DUT para cobertura obrigatória do medicamento**, de conformidade com as cláusulas contratuais, considerando-se, também, o conteúdo da Lei 9.656/98.

Nas relações contratuais, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Em assim sendo, da mesma maneira que os descumprimentos, por parte das operadoras de planos de saúde, das cláusulas contratuais desequilibram a avença originariamente pactuada impondo ônus excessivo a uma das partes, também o é a pretensão do segurado de obter benefício que não está previamente estipulado no contrato, e muito menos previsto em lei.

A consequência disso é a proliferação de demandas judiciais que poderia ser evitada pelo simples cumprimento contratual.

Ademais, para que o sistema privado de assistência à saúde seja mantido, é necessário que as obrigações de ambas as partes estejam claramente dispostas no contrato e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Importa salientar que, embora o Poder Judiciário não deva e nem possa fechar os olhos às mazelas sofridas pela população e, especificamente, pelas partes que trazem suas contendas e irresignações para julgamento, **não pode esse Poder querer impor às operadoras de plano de saúde o ônus de custear todo e qualquer procedimento**.

Nesse ponto, exsurge a importância do papel da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS na busca pelo equilíbrio nas relações existentes entre os usuários de plano de saúde e as operadoras.

Isso porque, antes da regulamentação do setor por intermédio da Lei 9656/98 e a criação da ANS pela Lei nº 9961/2000, as operadoras costumavam excluir dos contratos a cobertura para tratamento de diversas doenças, além de limitar o número de consultas médicas, dias de internação, sessões de fisioterapia, exames, idade para ingresso e até mesmo estabeleciam prazo o para permanência no plano.

Com a normatização e regulação do setor, houve uma homogeneização e ampliação da cobertura assistencial dos contratos de planos de saúde, o que decerto favoreceu o usuário. Paralelo a essas novidades, foram estabelecidas exceções à cobertura e obrigações à parte contratante.

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10º institui o **plano-referência de assistência à saúde** e estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. É por essa razão que existe o **Rol de Procedimentos e Eventos em** Saúde, uma lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A ANS, então, com base no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.961, de 2000, passou a editar normativos, instituindo e atualizando um rol de coberturas mínimas a serem garantidas pelos planos de saúde.

O referido rol, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 465, de 2021, estabelece uma lista de procedimentos e exames taxativa, uma vez que permite a ambas as partes, seja o usuário, seja a operadora do plano, ter uma previsibilidade quanto às coberturas asseguradas. Interpretar de forma diversa implicaria em impor custos não previstos quando da contratação do plano de saúde.

Atualmente há cerca de 3300 procedimentos de cobertura obrigatória. Pelo que não assiste razão a qualquer alegação de que este rol é exemplificativo (http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-rol-de-procedimentos (http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/737-rol-de-procedimentos).

O rol de procedimentos é revisado com a participação de um grupo técnico composto por representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de saúde, de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da ANS.

É, pois, inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas (RECURSO ESPECIAL Nº 1959187 – SP).

Isso não significa que todos os planos estão limitados a cobrir apenas o que consta na Resolução Normativa nº 465/2021, mas sim que tratamentos/procedimentos adicionais deverão constar expressamente no contrato.

É dizer, o Rol de Eventos em Saúde da ANS não é meramente exemplificativo. É nesse mesmo sentido o julgamento do REsp. 1.733.013 – PR da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. ***RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO****. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.*

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências – SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.
8. Recurso especial não provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.733.013 - PR (2018/0074061-5)

Nesse ponto, importa ressaltar que embora caiba ao médico assistente a decisão acerca do melhor tratamento, e conquanto haja tal liberdade, não se pode exigir da prestadora de serviços médicos que seja incumbida do pagamento de tratamento que, não estando previsto no contrato celebrado, nem no Rol da ANS.

Nesse sentido, os enunciados 21 e 23 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça instrui os magistrados a:

ENUNCIADO N.º 21: Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.º 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.

ENUNCIADO N.º 23: Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.

Ressalto, é evidente que cremos que o médico de confiança da parte Autora prescreveu o que entende ser o melhor tratamento para ela, mas, *não se pode descuidar da realidade das coisas, posto que mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não podem nortear a elaboração do rol, como, por exemplo: a) predileção por determinado procedimento ou mesmo maior domínio técnico/especialização a envolver a prática; b) familiaridade maior com o manejo de determinado exame, sendo, por exemplo, notório que a interpretação de cada tipo usualmente abrange complexidade e requer preparação específica do profissional da área (*RECURSO ESPECIAL Nº 1959187 – SP). E, uma vez que plano de saúde não é obrigado por lei nem pelo contrato a dar cobertura ao tratamento não deve o Poder Judiciário obriga-lo.

Pelo que foi exposto, concluo que não assiste razão à parte Demandante em querer compelir a demandada a cumprir obrigação pela qual não se obrigou seja pelo contrato firmado, seja pela legislação que lhe autoriza a atuar como operadora de plano de saúde.

Improcede, pois, o pedido consistente na obrigação de fazer.

Por fim, não é despiciendo ressaltar, que o alargamento, pelo Poder Judiciário das coberturas contratuais dos Planos de Saúde afeta o equilíbrio financeiro do seguro e, como é sabido de todos, as **operadoras de Plano de Saúde repassam as suas perdas para os demais** segurados. E, por consequência, todos suportam os gastos de uma parcela dos associados ao plano de saúde que, buscam, através de medidas judicias, obter tratamentos que não estão previstos em seus contratos, tampouco são de cobertura obrigatória.

No que diz respeito ao pedido de reparação civil, e tenho em vista que o plano de saúde réu não cometeu nenhuma conduta abusiva, pelo que igualmente imporcede o pedido de condenação em danos morais.

E, embora não constatada nenhuma abusividade do plano de saúde réu no caso dos autos, não é demais trazer à baila o entendimento do interprete da Lei Federal (no caso a Lei 9.656/1998) para situações como a dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DE ATO NORMATIVO DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. A despeito do reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir as despesas da cirurgia em virtude da existência de indicação médica, ***não é possível reconhecer que a recusa da operadora agravada, devidamente pautada por ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.***
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1645135/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)

Isto posto, com base nos dispositivos legais antes mencionados, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, com arrimo no art. 487, do Estatuto dos Ritos.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e da verba honorária de 10% sob o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se. Preenchidos os requisitos legais**, arquivem-se.**

Recife, data da assinatura eletrônica.

Lara Corrêa Gambôa da Silva
Juíza de Direito
34vcb1

Assinado eletronicamente por: LARA CORREA GAMBOA DA SILVA
29/11/2021 10:20:58
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 89593226